

1502498-25.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO OGACIR CATIONI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

APARECIDO OGACIR CATIONI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, II "j", do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502498-25.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502498-25.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO OGACIR CATIONI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

APARECIDO OGACIR CATIONI foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, II "j", do Código Penal

porque, em 02 de novembro de 2021, por volta de 19h00, em cenário de calamidade pública, depois de adquirir e receber de maneira escusa, o denunciado trazia consigo pela Rua Diná Sassi Steagal, altura do nº 490, nesta cidade, bem como guardava dentro de um posto de saúde desativado, imediações da “Escola Municipal Dercy Celia Seixas Ferrari” (fls.46), para entrega a consumo de terceiros, mediante venda, a caracterizar a traficância, drogas consistentes em 265 (duzentas e sessenta e cinco) porções de cocaína em pó, acondicionadas em microtubos de plástico do tipo eppendorf, com peso total de 46,452g (quarenta e seis gramas, quatrocentos e cinquenta e duas miligramas); e 40 (quarenta) porções de maconha, embaladas com invólucros plásticos, pesando 44,710g (quarenta e quatro gramas, setecentos e dez miligramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na data dos fatos, durante a pandemia gerada pelo novo coronavírus, que provoca a doença intitulada Covid-19, Aparecido resolveu comercializar entorpecentes no mencionado logradouro, estando em seu poder onze eppendorfs de cocaína e seis de maconha para rápida e imediata distribuição para usuários e dependentes químicos, além da quantia de R\$42,80 em cédulas e moedas, obtida com as vendas anteriores, escondendo num sofá de um posto de saúde abandonado o restante das drogas que pretendia vender, isto é, trinta e quatro porções de maconha e 254 de cocaína, mais R\$202,00 em dinheiro. Ocorreu que, ao ser abordado por uma mulher, para a qual iria entregar cocaína, o réu foi visualizado por policiais militares que realizavam patrulhamento rotineiro pelo bairro, os quais de pronto foram no encalço dos suspeitos, que fugiram ao notar a aproximação da viatura, tendo os agentes obtido êxito em deter apenas o ora denunciado, em cuja posse acharam as porções de substâncias estupefacientes anteriormente especificadas e o numerário. Em seguida os policiais realizaram buscas pelas cercanias e, nas dependências de um posto de saúde abandonado, localizaram o restante das drogas, escondidas no sofá por Aparecido, além de dinheiro. Indagado, de maneira informal, Aparecido admitiu a narcotraficância. Após regular apreensão (auto de fls.10/11), o material foi submetido à perícia, conforme laudo de constatação preliminar (fls.17/19) e exame químico-toxicológico (fls.52/54), atestando-se a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, e Metil Benzoil Ecgonina (cocaína).

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 37/39)

Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 63/64).

O réu foi citado (fls. 76) e apresentou resposta à acusação (fls. 80).

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2021 (fls. 81).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo o réu interrogado (fls. 84).

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu, em síntese, a procedência do pedido, pois materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo definitivo. A autoria também está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e B0, além dos depoimentos dos policiais, que apresentaram declarações seguras, detalhadas e coesas. Ressalta que não há circunstância que gere dúvida nas declarações dos policiais, uma vez que são agentes públicos e possuem presunção de veracidade. A majorante do delito também se aplica, pois o local onde o acusado foi preso é próximo a escola, não é necessário que o tráfico seja realizado visando os estudantes daquele local pois majorante tem caráter objetivo. Quanto à pena, na segunda fase da dosimetria, requereu que sejam observadas as agravantes da reincidência do acusado e calamidade pública, esta também objetiva. Na terceira fase, pede o afastamento da figura privilegiada, pois o réu é reincidente. Regime fechado, sem substituição, mantendo-se a prisão preventiva. Requereu ainda perdimento em favor da união dos valores apreendidos. A Defesa, por sua vez, afirmou que a pretensão punitiva não merece procedência, pois não há provas suficientes de que a droga apreendida pertencia ao acusado. O acusado negou a prática do tráfico, afirmando que compareceu no local para procurar a esposa que é usuária de drogas. Nega que portava droga consigo ou que estava no

local para vendê-la. Os policiais não conseguiram abordar a outra pessoa e, assim, não se pode descartar a hipótese de que essa pessoa seja a verdadeira dona das drogas, e não o réu. Ademais, o fato da pessoa ter conseguido fugir sugere que ela estava mais atenta à presença dos policiais, justamente por estar realizando o tráfico. Por essas razões, requer a absolvição do acusado. Deve-se ressaltar que a maior parte da droga foi encontrada em um sofá velho no imóvel abandonado e ambos os policiais narraram que o local é amplamente frequentado por diversas pessoas, sobretudo moradores de rua, de modo que não é possível imputar ao acusado a droga encontrada. Os policiais não narraram nenhuma circunstância que pudesse fazer inferir que esta droga era do acusado, já que não foi preso no sofá. Assim, pede o afastamento da presunção de que a droga pertencia ao acusado de acordo com a palavra dos policiais. Em caso de condenação, requer o afastamento da agravante da calamidade pública. Da mesma forma, seja afastada a causa de aumento de pena, já que não havia aulas naquele período, eis que era noite e dia feriado, estando a escola fechada e o crime imputado ao acusado não tinha potencial de atingir os frequentadores da escola. Uma vez que o acusado não é reincidente específico, pugna seja reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com regime aberto e recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 01/02, pelo B.O. de fls. 03/04, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11, pelo laudo de constatação provisória de fls. 17/20, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 52/54, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do crime também é certa.

A testemunha Paulo César Santana Júnior, policial militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pela rua citada, quando viram o acusado em ato de traficância, entregando algo nas mãos de uma mulher. Ele estava em frente ao portão de um imóvel da prefeitura, que parecia abandonado. Ao entrarem na via, o casal percebeu a presença da polícia, e a mulher começou a correr. Já Aparecido correu para dentro do imóvel. Como estavam perto, conseguiram abordar o acusado dentro do imóvel, a quatro ou cinco metros do portão da entrada. Ele não esboçou reação. Ao ser revistado, foi localizado em uma das mãos dele um kit, com onze porções de cocaína e seis porções de maconha. Na outra mão, foram localizadas notas de pequeno valor, que totalizaram R\$ 32,00. Nos bolsos havia moedas que totalizaram quase R\$ 10,00. Ele confessou que estava realizando o tráfico. Em vistoria no imóvel, verificaram que estava sendo usado por pessoas de rua. Havia um sofá velho e debaixo dele foram localizadas outras cápsulas de cocaína, pouco mais de 250 eppendorfs. Além de dez porções de maconha e volume grande de dinheiro, em notas miúdas, que totalizava aproximadamente R\$ 240,00. Não conhecia o acusado antes destes fatos. O local onde ele foi preso é um imóvel abandonado da prefeitura, não sabe o que funcionava antes. Não tem conhecimento se o local é usado por usuários de droga. O local é bem próximo de uma escola municipal em funcionamento, porém, no horário da abordagem, não havia estudantes. Era a noite e no momento do flagrante só havia uma mulher. Somente Aparecido foi abordado e identificado. A mulher não foi identificada e o acusado nada mencionou sobre ela. Não sabe se ela era estudante.

A testemunha Celso Ângelo de Oliveira, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e quando acessaram a rua viram o réu servindo uma porção de droga para uma mulher. Ao ver a viatura, ele correu para dentro do imóvel e a mulher evadiu-se pela via. Entraram no imóvel, abordaram o indivíduo e com ele havia onze porções de cocaína e seis parangas de maconha, além de R\$ 32,00 em dinheiro e moedas no bolso. De pronto, ele confessou a traficância, confirmando que estava "servindo" a mulher. Não conseguiram abordar a mulher. Viram o kit na mão dele. Dentro do local havia um sofá e viram mais porções de cocaína e maconha e mais de

R\$ 200,00. Ele confessou, disse que estava vendendo, mas não disse para quem ele vendia. O local está se tornando um ponto de tráfico, há várias denúncias. É um imóvel da prefeitura abandonado. Há uma escola ali perto, no mesmo quarteirão. Ele disse que estava "servindo" a mulher, mas não disse se a conhecia. Acredita que escola funcione somente durante o dia.

O réu, interrogado judicialmente, disse que tem 42 anos, segundo grau completo. Tem dois filhos, de 21 e 13 anos. Mora no Jardim Helena. Trabalha como soldador, porém em razão da pandemia estava há três meses desempregado. A esposa é usuária e nesse período estava auxiliando a esposa com reciclagem. Também é usuário, usa crack. Antecedentes por violência doméstica em 2015. É natural do estado do Paraná, está em Ribeirão Preto há um ano. Trabalhava em Jaguariúna como soldador, quando ficou desempregado veio para Ribeirão Preto, para a casa do pai. Veio para o estado de São Paulo quando criança, com três anos. Sobre os fatos, disse que estava com a esposa em casa e estavam bebendo e fazendo uso de drogas. Tiveram um "debate" e ela saiu de casa e foi até o local onde foi abordado. Foi atrás dela com uma sacola contendo apenas um garrafa de bebida alcoólica. Foi até esse local porque sabia que lá iria encontra-la. Adentrou no local, ela estava lá. Acredita que havia uma pessoa dentro também. O local é um ponto de droga, chamado "fumódromo". Foi abordado por policial à paisana. Estava na posse do celular, chave da casa e carteira. Não portava drogas e não admitiu a traficância. Os policiais trouxeram uma pessoa para dentro do local e passaram a agredi-lo. Eles, então, o colocaram dentro da viatura. A esposa estava sentada na calçada. Não foi informado porque estava sendo preso. Ficou sabendo que foi achada droga e quantidade de dinheiro no CDP. Não é traficante e não tinha drogas consigo. Pega reciclagem na rua para sustentar seu vício. Questionado sobre a mulher, disse que a esposa saiu primeiro de casa e a encontrou dentro do local. Não sabia o que estava acontecendo. Ela estava dentro do imóvel usando drogas. Depois saiu. Entrou dentro do imóvel para comprar droga com os R\$ 10,00 que tinha. Quando não mais havia ninguém no local, foi abordado. Não estava com a esposa, não foi abordado com ela e também não portava nada ilícito. Foi até o local buscar a esposa que estava lá e ao mesmo tempo comprar droga, iria comprar crack. Não conhecia os policiais. Não sabe dizer o porquê de os policiais "colocarem" a droga em si. Eles abordaram uma pessoa do lado de fora e levaram-na para dentro do imóvel, bateram nele, não sabe quem é, mais o viu. Em seguida, os policiais o colocaram na viatura e foi sozinho para a delegacia.

Pois bem. Em que pese a negativa do réu e a versão de existência de outras pessoas na cena do crime e "forja" de drogas por parte dos policiais responsáveis pela prisão, após regular instrução processual verifico que as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico.

Como se viu, o acusado negou que estivesse na posse de drogas, afirmando que tinha ido ao local, um fumódromo, para buscar a esposa que é usuária.

Contudo, os policiais militares ouvidos em juízo relataram que durante patrulhamento visualizaram o acusado entregando drogas para uma mulher, que fugiu e não foi identificada. Com a aproximação da viatura, o acusado correu para dentro do imóvel, onde foi abordado. Encontraram em suas mãos 11 eppendorfs de cocaína e 06 porções de maconha, além da quantia de R\$ 32,00 em dinheiro e aproximadamente R\$ 10,00 em moedas. Já no imóvel sítio dos acontecimentos, debaixo de um sofá velho, os policiais encontraram R\$ 200,00 em dinheiro, 254 eppendorfs de cocaína e 34 porções de maconha.

Os policiais narraram ainda que o réu informalmente lhes confessou o delito, tao logo foi abordado.

As versões apresentadas pelos policiais são firmes elementos de prova, absolutamente aptos a dar sustentação à condenação dos acusado. Os depoimentos foram harmônicos, detalhados e coesos, inclusive, com aqueles prestados perante a autoridade policial por ocasião da apreensão das drogas.

A palavra dos policiais não pode ser desacreditada, pois eles estavam exercendo a função de policiamento ostensivo, inerente ao cargo em que foram investidos, devendo, pois, seus depoimentos serem aceitos por terem fé pública, e, ainda mais, porque coerentes com outros elementos dos autos.

Quanto a legalidade e validade dos depoimentos, eis a jurisprudência

"TRÁFICO DE DROGAS AUTORIA depoimentos de policiais que confirmam a apreensão de drogas na sacola que o réu trazia nas mãos validade depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inoocorrência no caso em tela - de rigor a condenação do réu improvimento ao apelo do réu." (TJSP. Apelação Criminal nº 1515140-97.2020.8.26.0228. Relator: Lauro Mens de Mello. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/04/2021)

Em sendo assim, o depoimento de agente público só deve ser visto com reservas quando se verificar a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não conheciam o acusado, não havendo motivos para imputar-lhe falsamente a prática de delito.

Os policiais foram muito incisivos no sentido de que o réu confessou a traficância. Ademais, ele foi visto "servindo" a mulher e foi abordado após entrar no imóvel, na posse de denominados "kits" contendo porções de cocaína e maconha, além de quantia em dinheiro em notas miúdas e moedas.

Ainda que o droga encontrada dentro do imóvel, debaixo do sofá, não pertencesse ao acusado, já que o local era usado também por outras pessoas, usuários e moradores de rua, a apreensão da outra parte da droga nas mãos do imputado, além de dinheiro, e especialmente o fato de ter sendo visto entregando tóxicos à mulher que se evadiu, já evidencia a traficância.

Assim, não há espaço para a versão do réu. Ele apresenta um álibi, que é o seu encontro com a sua mulher, contudo a Defesa não o provou adequadamente.

Além disso, comprovada a traficância, entendendo que não há espaço para a desclassificação da conduta do réu para aquela do artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendida não condiz com a consumida por meros usuários de drogas.

O fato de ser o réu dependente químico não afasta a condição de traficante, devidamente comprovada nestes autos, pois, é bem sabido que muitas vezes usuários de drogas passam a exercer a traficância com o intuito de obter dinheiro para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (RJTJ 101/498).

No que toca à majorante do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343, de rigor o seu afastamento.

Isso porque a mera proximidade física, sem que provada a maior suscetibilidade dos alunos e professores à oferta da droga comercializada pelo réu, não é suficiente para o incremento da pena.

Nesse sentido, os policiais nada relataram se o tráfico do réu atingia, de fato, alunos e professores daquela escola, além de que os fatos se deram em um dia não-letivo, quando a escola estava fechada.

O critério meramente objetivo de proximidade não prevalece isoladamente, havendo de estar demonstrado, por outros elementos de convicção idôneos, que o réu visava a alcançar indivíduos daquela escola em sua atividade comercial. Não fosse assim, tal majorante se tornaria uma constante em todos os crimes de tráfico cometidos em cidades, eis que os locais descritos no rol do inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas são típicos de qualquer aglomeração urbana.

Há que se demonstrar, a meu ver, que a prática delitiva envolvia, ainda que de forma indireta, os frequentadores do estabelecimento de ensino ou a eles ocasionava prejuízo concreto, maior que aquele normalmente sofrido pela sociedade como um todo em razão do cometimento de crime dessa natureza, evidenciando-se, assim, o maior desvalor da conduta ou do resultado do delito, o que não ficou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico majorado. Art. 33 c.c. art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/06. Traficância realizada nas proximidades de escola e em concurso com adolescente. Participação de adolescente no delito que é suficiente para a incidência da majorante do inciso VI, não sendo necessário que o menor seja o consumidor do entorpecente. Tráfico que, embora realizado próximo a estabelecimento de ensino, se deu em um domingo à noite. Teleologia da norma que pune com maior gravidade o traficante em razão da possibilidade de atingir os estudantes. Caso em apreço que impõe seu afastamento. Recurso provido em parte." (TJSP. Apelação nº 0001007-68.2014.8.26.0444. Relator: Reinaldo Cintra. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 29/10/2015)

No mais, impõe-se o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j" do CP, por não haver prova de que o réu se valeu do estado de calamidade pública para cometer o crime.

Duradoura a pandemia vivenciada e retomados, em grande parte, a vida cotidiana dos cidadãos e os serviços públicos, não há que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento de tal situação por parte do acusado.

Nesse sentido, a decisão recente do E. TJSP:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Material probatório que estaria circunscrito aos depoimentos prestados pelos guardas municipais responsáveis pela prisão do acusado os quais devem ser recebidos com reservas. Pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Pleitos subsidiários: a) afastamento da circunstância agravante referente à calamidade pública; (...) 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa. 3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal nº 1510664-16.2020.8.26.0228. Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/12/2020)

Passo à dosagem da pena:

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisadas em conjunto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifico que o réu reincidente, o que será valorado na segunda fase de aplicação da pena. A quantidade da droga não é grande para justificar o incremento nesta primeira fase. Assim, fixo a pena-base no piso, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, cada qual no piso legal.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (Processo 0000171-82.2015.8.26.0631 - fls.24), portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no piso legal. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Ainda, não é caso de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é reincidente ainda que não específico.

Assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ante a reincidência do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO ANTONIO OGACIR CATIONI, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no seu valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Mantenho o acusado preso, por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir e pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da custódia do acusado que ainda se encontram presentes.

Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Por ser produto de crime, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA